

1501667-94.2021.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... por sua vez, a incompatibilidade do tráfico profissional praticado, no caso, com o instituto do privilégio.

Em linha de remate, propugnou pela fixação do regime fechado para o início da execução da pena, e, ainda, que não seria cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em razão do tráfico reiterado e da natureza da droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

1ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501667-94.2021.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501667-94.2021.8.26.0297

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279628/2021 - 01º D.P. JALES, 20805069 - 01º D.P. JALES, 3635/21/227 - 01º D.P. JALES, 2279628 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEUDIANE BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Vistos.

CLEUDIANE BATISTA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, em conformidade com os termos vertidos na exordial acusatória, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 17h50, na rua Treze, nº 1278, Centro, na cidade de Jales, a ré transportou e trazia consigo 02 (duas) porções grandes (tipo tijolos) de cocaína, na forma de crack, com peso bruto de 1.686,96 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico.

Nos termos da prefacial acusatória, na data dos fatos, a ré embarcou em um ônibus

da empresa Expresso Itamaraty, que partiu da cidade de São Paulo com destino à Jales, trazendo consigo duas porções grandes de cocaína (na forma de crack).

Nos termos da incoativa, um policial à paisana, que também viajava no mesmo ônibus com sua família, notou que a ré aparentava intenso nervosismo durante o trajeto e, assim, comunicou o fato aos policiais militares da cidade de Jales.

Colhe-se, ainda, nos termos da denúncia, quando o ônibus estacionou na rodoviária de Jales, que a ré foi abordada por policiais militares que constataram que ela trazia consigo uma bolsa, no interior da qual estavam escondidos os entorpecentes apreendidos.

Dos termos da peça acusatória, colhe-se, ademais, que, após negativa inicial, a ré confessou o transporte da droga aduzindo que a entrega dela seria feita para uma pessoa da cidade de Pontalinda (SP), e, por sua vez, que receberia seiscentos reais como pagamento pelo transporte.

Colhe-se, outrossim, nos termos da denúncia, que a ré é reincidente específica, com duas condenações anteriores pela prática do tráfico de drogas.

Eis, em compêndio, os termos da denúncia (fls.140/143).

A ré foi notificada dos termos da denúncia (fls. 210), de sorte que, no comenos oportuno, por intermédio de sua defensora, ofereceu a abalizada defesa preliminar (fls.152/161).

Nada obstante, sem embargo da defesa, a denúncia acabou sendo recebida (fls.171/175), em 14 de junho de 2022.

Na data aprazada, houve a colheita da prova oral, ouvindo-se, na oportunidade, quatro testemunhas. A ré, por sua vez, foi ouvida em sede de interrogatório, por intermédio do qual exerceu a sua autodefesa.

Ao cobro da instrução, primeiramente, como sói ocorrer, manifestou-se o Ministério Público, na lavra de sua Ilustre Promotora de Justiça, a qual, em sua faina, pugnou pelo acolhimento da pretensão acusatória, averbando, no ponto, que a comprovação da materialidade ficou estampada no auto de prisão em flagrante (fls.01), auto de exibição e apreensão (fls.11/12), laudo de constatação (fls.14/19), laudo de exame químico toxicológico (fls.90/92), e rebatimentos fotográficos (fls.26/30), bem como pela prova oral colhida nos autos, e, outrossim, que a autoria restou incontroversa.

Sublinhou, a seu turno, que os elementos produzidos nos autos conferem segurança à procedência da ação penal.

Pontou, ainda, para além da confirmação da ré aos policiais de que estava transportando droga, que os relatos dos policiais foram coesos e harmônicos em relação ao fato, e, outrossim, que a palavra dos agentes policiais goza de fé pública, com valor probatório, mormente sob o crivo do contraditório.

Averbou, em adição, que, não existindo nos autos elementos desabonadores dos depoimentos policiais, sem prova de que eram desafetos da parte acusada, ou que quisessem prejudica-la, eventual condenação pode ser baseada nestes depoimentos.

Esgrimiu, a seu turno, que as circunstâncias da prisão em flagrante da ré, a quantidade de cocaína na forma de crack, e o modo de acondicionamento, denotam que a ré estava se dedicando à traficância.

Ao incursionar sobre a dosimetria da pena, no que alude à pena base, pugnou por sua

exasperação, considerando, a sua vez, a natureza da droga e o alto teor intoxicante da cocaína (na forma de crack).

Na segunda fase, apontou a agravante da reincidência específica, bem como a atenuante da confissão, averbando, a seu turno, que a agravante prepondera sobre a atenuante, sendo incabível a sua compensação.

De sua vez, na terceira fase, sustentou a impossibilidade da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, consignando, a seu turno, a natureza deletéria da droga, a reincidência específica da ré, apontando, por sua vez, a incompatibilidade do tráfico profissional praticado, no caso, com o instituto do privilégio.

Em linha de remate, propugnou pela fixação do regime fechado para o início da execução da pena, e, ainda, que não seria cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em razão do tráfico reiterado e da natureza da droga (fls.234/249).

A defesa, por seu turno, palmilhando senda visceralmente oposta, bateu-se pela absolvição, averbando, em escorço, a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de provas concretas para sustentar um decreto condenatório.

Pontuou, ainda, que, dos depoimentos apresentados e nos termos contidos na denúncia, não se extrai a prática do núcleo do tipo penal contido no art. 33, da Lei nº 11.343/06, pela ré.

Salientou, outrossim, que os depoimentos colhidos durante a instrução não foram hábeis para conferir absoluta certeza a uma sentença penal condenatória, sustentando a existência de dúvidas sobre a mercancia da droga pela ré, averbando, ainda, que a apreensão de drogas não é meio apto para condenar a ré por tráfico de drogas.

Nessa quadra, ressaltou que não foram trazidos aos autos elementos suficientes, tais como, manuscritos contábeis, instrumentos de individualização de drogas, voluptuosa quantidade de dinheiro, que indicassem o comércio ilícito, e, ainda, que não houve a apreensão de dinheiro com a ré.

Averbou, ainda, que a acusada sempre se dedicou ao trabalho lícito, consoante o depoimento das testemunhas Larissa e Ana Claudia.

Destacou, a seu turno, que o celular da acusada foi periciado e que nenhuma mensagem, ou foto, foi encontrada a fim de evidenciar o seu envolvimento com tráfico de drogas.

Subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria, pugnou pela fixação da pena base em seu mínimo legal, averbando, a seu turno, que todas as substâncias entorpecentes são danosas, e, por sua vez, que, em razão disto, ocorreria uma a exasperação automática.

Na segunda fase, propugnou, a sua vez, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, e, outrossim, por sua compensação com a agravante da reincidência. Na terceira fase, requereu a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com redução no patamar de 2/3 (dois terços).

Em linha de remate, pugnou pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, expedindo-se o abalizado alvará de soltura, ou, ainda, que seja estabelecido um regime menos severo.

Pugnou, ao final, pelo reconhecimento do período em que a ré esteve presa

provisoriamente, para fins de eventual detração e fixação de regime mais brando, requerendo, ainda, o direito de recorrer em liberdade, em razão de a ré ser genitora de duas crianças, pugnando, outrossim, pela fixação de prisão domiciliar para o cumprimento da pena, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Requeru, em adição, a restituição do aparelho celular apreendido (fls. 251/264).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece ser parcialmente agasalhada.

A materialidade do delito imputado, a rigor, se encontra estribada no auto de prisão em flagrante (fls.01), no auto de exibição e apreensão (fls.11/12), nos rebatimentos fotográficos (fls.26/30 e 33), no laudo de constatação (fls.14/19), no laudo de exame químico toxicológico (fls.90/92), no relatório final da Polícia Civil (fls.97/98), e, também, pela prova oral coligida.

A autoria, no mesmo toar, se coloca de forma estreme de dúvidas, na medida em que a confissão da ré, em pretório, encontrou supedâneo no conjunto probatório amealhado nos autos.

Da acendrada análise dos autos, colhe-se, em compêndio, da prova oral coligida que, a testemunha Willian Felipe Pajares, de sua vez, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que, na data do fato, o seu parceiro de viatura, o Cabo Targa, recebeu uma informação de um policial à paisana, que estava dentro do ônibus, sentado bem próximo da ré. Disse, em adição, que as informações foram transmitidas ao Cabo Targa, bem como ao Sargento que estava na equipe do dia. Relatou, a seu turno, que a ré foi abordada no momento do desembarque do ônibus, no terminal rodoviário. Afirmou, em acréscimo, que foram encontradas duas peças de crack no interior da mochila da ré, e, por sua vez, que, imediatamente, a ré negou a propriedade desta mochila. Relatou, ainda, que, na ocasião, a ré declarou que uma pessoa no terminal Barra Funda tinha entregado a mochila, e, outrossim, que, na Delegacia, a ré declarou que a droga pertencia à Maria Rita, de Pontalinda, informando, a seu turno, que a Maria Rita é pessoa conhecida nos meios policiais pelo vulgo de "Pandora". Disse, por sua vez, que a ré declarou que receberia R\$600,00 para buscar a referida mochila no terminal Barra Funda. Informou, outrossim, que, segundo a ré, a Maria Rita custeou a viagem, informando, a seu turno, que a ré estava na posse de um cartão de crédito com o nome da Maria Rita.

A testemunha Dimas Michel Targa, ao prestar seu depoimento em pretório, disse que, na data do fato, estava de serviço, na companhia de seu colega Pajares, quando recebeu uma ligação telefônica de um policial à paisana, que estava viajando com a família dele de São Paulo para Jales. Disse, ainda, que o policial à paisana percebeu uma atitude suspeita da ré, informando, outrossim, que ela estava muito nervosa, e, a seu turno, que este policial percebeu a ré enviando mensagens pelo celular e apagando em sequência, em razão da sua proximidade. Narrou, por sua vez, que foram ao terminal rodoviário e fizeram a abordagem da ré no momento do seu desembarque. Relatou, outrossim, que indagaram se a ré estava transportando algo ilícito, e, ainda, que fizeram a vistoria da sua bolsa, informando, a seu turno, que a ré, neste momento, negou a propriedade da bolsa. Disse, em adição, que, na ocasião, a ré declarou que tinha recebido R\$ 600,00 para fazer o transporte, e, por sua vez, que encontraram dois pedaços grandes de crack na bolsa, momento em que a ré assumiu ter feito o transporte da droga, negando, a sua vez, a propriedade do entorpecente. Informou, ainda, que uma das peças de droga estava destinada à Maria Rita, da cidade de Pontalinda, informando, a seu turno, que, na data do fato, houve a apreensão de um cartão em nome da Maria Rita, o qual, segundo a declaração da ré, foi utilizado para as despesas da viagem. Disse, em acréscimo, que a ré declarou, na ocasião, que a outra parte da droga estava destinada a uma pessoa em Jales, descrevendo alguém com compleição física baixa e gorda, possuindo a tatuagem de uma

rosa no antebraço. Narrou, a seu turno, que a policial feminina, que estava presente no local, fez uma vistoria pessoal na ré, localizando uma porção de maconha no interior do seu sutiã. Confirmou, ainda, que a porção de maconha foi apreendida com a ré. Relatou, por sua vez, que no interior da mochila da ré foram encontradas roupas pessoais e duas pedras grandes de crack, pesando, aproximadamente, 0,5kg cada uma. Afirmou, a seu turno, que a ré foi abordada no momento do seu desembarque, confirmando, ainda, que ela trazia consigo a bolsa, à tiracolo. Disse, a sua vez, que não se recorda de ter feito a apreensão de algum valor junto à ré, informando, ainda, que ela estava no posse de um cartão, e, a seu turno, que a ré declarou que este cartão lhe foi entregue para o custeio da viagem.

A testemunha Larissa Camili Anastácio da Silva, a seu turno, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que não possui relação de parentesco com a ré, e, por sua vez, que são amigas. Informou, por sua vez, que, na época do fato, trabalhava junto com a ré em um hotel, em frente à "Radical Jales", sem registro, informando, ainda, que faziam faxina e que ganhavam R\$ 100,00 por dia. Disse, ainda, que, às vezes, solicitava faxinas à ré em sua casa, e que pagava R\$ 100,00. Relatou, a seu turno, que faziam a limpeza do hotel todos os dias. Confirmou, ainda, que, além do hotel, tinha conhecimento de que a ré também fazia faxina em outras casas como diarista, informando, outrossim, que a ré sempre trabalhou como diarista, mencionando, a seu turno, que a ré também fazia faxina para outras pessoas da sua família. Relatou, por sua vez, que a ré sempre foi uma pessoa tranquila, de boa índole, e que nunca ouviu relatos desabonadores a seu respeito, e, ainda, que se trata de uma pessoa trabalhadora. Afirmou, ainda, que a ré possui filhos, afirmando, outrossim, que ela não os trouxe, quando de sua vinda.

A testemunha Ana Claudia Lacerda, a seu turno, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que conheceu a ré na casa da sua mãe e da sua irmã. Disse, outrossim, que já conseguiu um trabalho de faxina para a ré, em uma oportunidade, há bastante tempo, informando, a seu turno, que também trabalha com faxinas. Informou, ainda, que não se recorda a quem indicou a ré, e, outrossim, que perdeu o contato do seu celular. Afirmou, a seu turno, que a ré é uma pessoa trabalhadora, negando, ainda, ter conhecimento de que a ré tenha praticado outros crimes.

A ré Cleudiane Batista, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, disse que completará 34 anos de idade no dia 30 de agosto, informando, ainda, que, anteriormente ao fato, estava morando com o seu marido, na cidade de Pontalinda. Narrou, a seu turno, que possui 3 filhos, e, na ocasião, estava com o seu aluguel atrasado, com vencimento no dia 17, e, por sua vez, que viajou no dia 13. Relatou, outrossim, que estava há 2 meses sem trabalho, informando, a seu turno, que, por conta da pandemia, as oportunidades de emprego ficaram escassas. Disse, ainda, que uma pessoa surgiu, querendo contratá-la, afirmando, por sua vez, que a desconhecia. Narrou, em adição, que, por conta do aluguel vencido, bem como do serviço de luz e água interrompidos, e que passava por muitas dificuldades, que aceitou a realização da viagem. Disse, em adição, que se arrepende muito. Afirmou, ainda, que não sabe informar o critério eletivo utilizado para que fosse escolhida nessa viagem, afirmando, outrossim, que, na época, muitas pessoas a estavam ajudando em Pontalinda. Relatou, em acréscimo, que, possivelmente, alguém soube de seu estado de necessidade e a contratou. Afirmou, por sua vez, que a contataram por intermédio do facebook, informando, ainda, que, inicialmente, houve uma conversa normal com a pessoa contratante, e que passou a descrever sua necessidade de emprego. Disse, em adição, que acredita que o seu estado de necessidade chamou a atenção dessa pessoa. Narrou, ainda, que publicou nas redes sociais que estava precisando de emprego, e, por sua vez, que uma certa pessoa lhe perguntou se tinha coragem de viajar. Disse, a sua vez, que estava precisando de trabalho para pagar o seu aluguel e atender a necessidade dos seus filhos, afirmando, ainda, que, em razão disto, aceitou a proposta. Confessou, ainda, que receberia a quantia de R\$600,00, na sexta-feira, sendo necessário buscar uma bolsa, na Barra Funda, e entregá-la na cidade de Jales, relatando, a seu turno, que foi informada de que a bolsa continha droga, e, por sua

vez, que não foi informada do tipo da droga. Afirmou, por sua vez, que somente aceitou a proposta em razão dos seus filhos e da difícil situação econômica, informando, outrossim, que tem grande arrependimento. Narrou, a seu turno, que identificou a pessoa que estava com a bolsa, na estação Barra Funda, descrevendo as suas roupas e características para a pessoa no facebook, e, por sua vez, que esta pessoa repassou as informações para outra, que, efetivamente, faria a entrega da bolsa. Relatou, em acréscimo, que, ao chegar no local, a pessoa que faria a entrega da bolsa a reconheceu, vindo em sua direção, reconhecendo a marca "Fila" em sua blusa. Afirmou, ainda, que, na ocasião, encontrou-se com um homem, e que o desconhecia, afirmando, outrossim, que ele apenas lhe entregou a bolsa, não falando nada. Narrou, a seu turno, que foi orientada, quando chegasse em Jales, da mesma forma, de que alguém se aproximaria para receber a droga, assim como aconteceu com o homem, e que seria identificada por suas vestimentas. Disse, em adição, que receberia o seu pagamento por meio de uma conta que seria criada para esta finalidade. Afirmou, ainda, que o cartão que estava em sua posse pertencia a uma amiga, que trabalhava como manicure, afirmando, outrossim, que ela lhe solicitou a compra de alguns itens no Brás, e, por sua vez, que não conseguiu ir ao Brás, e que foi apenas à Barra Funda. Negou, a seu turno, que tivesse declinado aos policiais os destinatários das drogas, afirmando, ainda, que os desconhecia. Disse, em adição, que desconhece o motivo pelo qual os policiais mencionaram o epíteto da destinatária da droga, afirmando, outrossim, que não existe este registro em seu depoimento. Negou, por sua vez, que tivesse declarado, em algum momento, que o cartão que possuía, na data do fato, estava destinado ao custeio da sua viagem. Negou, a seu turno, que tivesse realizado alguma compra no Brás, informando, ainda, que não teve tempo. Afirmou, ainda, que o seu contratante tinha feito o pagamento das passagens de ida e volta, informando, por sua vez, que somente foi até a Barra Funda. Informou, em acréscimo, que viajou no dia 12 e retornou no dia 13. Relatou, por sua vez, que estuda na unidade prisional, desde quando chegou, afirmando, ainda, que está trabalhando há dois meses em uma empresa, internamente. Disse, ainda, que, anteriormente ao fato, trabalhava no edifício "Los Angeles", na Rua Treze, em frente à bicicletaria "Radical", durante 4 meses, na portaria e na limpeza, sem registro, cobrindo o afastamento de outra empregada, que estava doente. Disse, a seu turno, que se arrepende muito, e, ainda, que, atualmente, tem a experiência do que significa ter uma conduta ilícita.

Diante da prova oral produzida, mister algumas ponderações.

Passando em revista aos elementos de convicção amealhados, notadamente aqueles que despontaram da prova oral, conclui-se, de forma cartesiana, que a apreensão da droga é indubitosa.

Impende salientar, neste particular, que, para além dos depoimentos coesos, lúcidos e seguros das testemunhas, os quais não se revelaram disformes, a ré, de forma hialina, ao exercer a sua autodefesa, evidenciou que, em verdade, se dirigiu à estação Barra Funda, na cidade de São Paulo, com o fito de ingressar na posse de uma sacola contendo a droga apreendida, a qual deveria ser transportada a Cidade de Jales, mediante remuneração.

Neste eito, indisputável que era cônica do fato de que estava transportando droga, bem como que o fez com o intuito de lucro, sendo sabedora que a droga seria mercadejada, na medida em que a quantidade apreendida, notadamente ao considerarmos a sua natureza, a bem da verdade, seria absolutamente incompatível com o uso.

Sobreleva notar, neste particular, que a ré, sem claudicar, confessou que foi contratada para o transporte da droga, e, por sua vez, que somente aceitou a proposta em razão do seu estado de necessidade, de molde que o cenário da traficância, ao cobro da instrução, despontou como indisputável.

De todo modo, mister sublinhar, por ocupar praça relevante, que, no caso em

tablado, malgrado a ré ter ventilado eventuais problemas socioeconômicos a ensejar a sua conduta, a rigor, não cuidou em trazer à colação qualquer elemento de convicção a suportar eventual situação de vulnerabilidade social, de sorte que, a base argumentativa sem qualquer substrato probante, a rigor, desponta como insuficiente para valoração.

Nessa linha de intelecção, não soçobram dúvidas acerca da materialidade delitiva e de sua respectiva autoria.

Conforme gizado, a despeito do comportamento criminalizado ter despontado como evidente, em certa medida, a ré buscou justificar a assunção da responsabilidade pelo transporte, aduzindo, no ponto, que estava passando por privações financeiras.

Nada obstante, não restou demonstrado, de forma clara, qualquer situação de exculpação fundada em hipótese de extraordinária anormalidade das circunstâncias da vida a ensejar o reconhecimento de inexigibilidade concreta de comportamento diverso em virtude da impossibilidade de dirigibilidade normativa.

Deveras, malgrado a asserção de dificuldades econômicas, não restou demonstrado um conflito de deveres, onde o comportamento adotado seria o único caminho a ser palmilhado para garantir a sua própria sobrevivência ou de seus familiares (situação de exculpação supralegal).

De sua vez, a despeito de a defesa ter asseverado que, em verdade, não teria realizado o núcleo do tipo preconizado no artigo 33 da Lei de Drogas, não quadra censura o asserto no sentido de que o tipo penal preconizado no artigo 33 da Lei de Drogas, a rigor, é multinuclear, e, para a sua consumação, basta a execução de qualquer uma das ações nucleares previstas no tipo penal.

Nesse modal de ideias, ainda que não demonstrada a comercialização da droga apreendida, o singelo transporte para entrega a terceiros, com o escopo de venda, desponta como suficiente para configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

De sua vez, no concernente à fixação da pena, calha trazer à talho algumas considerações.

Sem embargo do respeito e estima que nutrimos pela Ilustre Promotora de Justiça, ousamos discordar do seu entendimento no sentido de que a pena deve ser exasperada em razão de sua maior nocividade à saúde, porquanto, a rigor, toda droga, é nociva à saúde.

Neste eito, partindo-se da premissa que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, o aspecto danoso da droga para saúde pública já foi valorado pelo legislador ao criminalizar a conduta e estabelecer os balizamentos sancionatórios, no âmbito do preceito secundário.

Noutros dizeres, considerando-se o pretense bem jurídico tutelado, a saber, a saúde pública, a rigor, ao criminalizar o comportamento de fornecer, vender, guardar e transportar drogas, o legislador ao estabelecer os balizamentos das penas mínima e máxima, a bem da verdade, já considerou e sopesou os efeitos deletérios da droga para a saúde do usuário.

Por sua vez, na segunda fase do sistema trifásico, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante dimanada da confissão da prática do delito de tráfico.

A outro giro, sem embargo da existência do registro encontrado a fls. 44 dos autos

(processo 1500043-95.2019.8.26.0356), o qual suporta o reconhecimento da reincidência específica, mister considerar que, na fase da fixação da pena provisória, a reincidência deverá ser compensada com a confissão.

Deveras, quadra aqui destacar que, em verdade, a confissão espontânea apresenta caráter preponderante, de tal arte que, a rigor, deve compensar a preconizada reincidência, de sorte que, deve ser mantida inalterada a pena base a ser fixada.

A seu turno, conquanto a reincidência plasmada na certidão de fls. 44 dos autos, arrede, de forma pontual, o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, o qual a rigor não se trata de tráfico privilegiado, mas, sim, de hipótese de redução de pena, devemos ter em consideração que ao ser considerada a reincidência para alijar a minorante, não deverá ser sopesada para fins de exasperação da pena, na fixação da pena provisória, na segunda fase do sistema trifásico, sob pena de indisputável bis in idem.

Com efeito, a dupla valoração da mesma circunstância para recrudescer a situação da ré, na fixação da pena, acaba por render azo ao bis in idem.

Nessa linha de intelecção, Paulo Queiroz preconiza a aplicação analógica da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, vazada nos seguintes termos: “A reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. (Queiroz, Paulo. Comentários à Lei de Drogas Editora JusPODIVM).

Colhe-se, outrossim, da dogmática abalizada o seguinte excerto: “Houve, portanto, bis in idem, porque a mesma circunstância incidiu, mais de uma vez, na individualização da pena, implicando, por duas vezes, um aumento da reprimenda, ora como agravante, ora como circunstância impeditiva da redução da pena. (...) Como vimos, sempre que tal ocorrer, deve predominar a circunstância que mais aumenta ou que mais diminua a pena, razão pela qual, no caso, há de prevalecer como causa impeditiva do privilégio (artigo 33, §4º, da Lei), sendo desprezada enquanto agravante legal”. Queiroz, Paulo. Comentários à Lei de Drogas Editora JusPODIVM, p.55/56).

Nessa linha de intelecção, a reincidência, não deve ser duplamente valorada para fins de recrudesimento da situação da ré.

De outro bordo, no caso em apreço, entendemos que a detração deverá ser analisada pelo juízo da execução penal.

Com efeito, a rigor, trata-se de competência concorrente.

Contudo, invariavelmente, o juízo da execução penal se encontra muito mais aparelhado para análise, porquanto, para além do período de prisão provisória, mister a análise de condições subjetivas, que recomendam a análise do atestado de conduta carcerária, da reincidência, de outras execuções em curso, de sorte que, tais circunstâncias relevantes para definição do regime poderão ser analisadas, com maior segurança e clareza, nos termos do art. 66, inciso III, "c", da Lei de Execução Penal, pelo juízo da execução penal.

Deveras, invariavelmente, o juízo da execução penal é quem, de fato, dispõe de todos os elementos cognitivos que permitem a análise do histórico de condenações, das execuções em curso, bem como do comportamento carcerário, a ensejar, por conseguinte, o reconhecimento que a análise pelo juízo da execução penal se relava mais consentâneo.

De outra banda, de ver-se que, não há de se falar em prejuízo à ré, porquanto, na contingência de ser fixado o regime fechado, inalterados os requisitos da prisão preventiva, com a interposição do recurso, ao ser recebido, será determinada a

expedição de guia de execução provisória.

Por sua vez, não se tratando de título judicial definitivo, porquanto não há o trânsito em julgado, não divisamos cenário compatível com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não despontaram dos autos elementos seguros no que concerne ao fato de a ré ser a responsável exclusiva pela guarda, criação, educação e cuidado dos menores, não havendo demonstração estreme de dúvidas no sentido de que seria a responsável pelos cuidados diários dos menores, de forma exclusiva ou predominante, morando com estes, e, de forma direta, pessoal e exclusiva, zelando pela alimentação, afeto, cuidados, educação, proteção e condução da vida dos seus filhos.

A outro giro, no âmbito da execução penal, a rigor, a prisão-albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, somente tem cabida aos condenados que se encontram no regime aberto.

Nada obstante, de forma excepcional, tem-se admitido o deferimento da prisão domiciliar em outras hipóteses, em situações excepcionais, nas quais reste patenteado o grave estado de saúde e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional no qual se cumpre a pena, ou, ainda, em outras situações timbradas por circunstâncias humanitárias.

De todo modo, com a expedição da guia de execução provisória, e, ao depois, caso confirmada a condenação, com o trânsito em julgado, num primeiro momento, a sentenciada, e, ao depois, com o trânsito em julgado, a executada poderá pleitear eventual concessão da prisão-domiciliar junto ao juízo da execução penal competente, demonstrando, verbi gratia, uma das hipóteses preconizadas no artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Com efeito, na quadra atual, por razões humanitárias, a jurisprudência flexibilizou a necessidade de que o sentenciado se encontre no regime aberto, de molde que vem sendo admitida a concessão da prisão domiciliar para presos do regime fechado ou semiaberto.

Nessa quadratura, não havendo prova segura no sentido de a ré é a única responsável pelos cuidados pessoais de seus filhos, não havendo outros parentes em condições de fazê-lo, por ora, junto a este juízo, o seu pleito não deve ser acolhido.

Enfrentados os pontos nodais que ferem o mérito, passo, doravante, à dosimetria da pena, louvando-me, para tanto, do sistema trifásico.

Passando em revista aos termos do art. 59 do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da quantidade de drogas apreendidas, a pena deverá ser exasperada em 1/6. De sua vez, a ré não ostenta, na ótica da leitura constitucional, eventuais registros desabonadores que possam ser considerados como maus antecedentes. De resto, à falta do suporte probatório mínimo nada há a ser levado em consideração no que alude à personalidade da ré, tampouco no que toca às circunstâncias e consequências do crime. Por seu turno, no mesmo viés, nada a ser considerado no que alude aos motivos do crime e à sua conduta social. Nesse toar, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, atribuindo-se a cada dia multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando-se, para tanto, a ausência de elementos que digam com a maior capacidade econômica por parte da ré.

De outra banda, no que concerne à pena provisória, a confissão espontânea, em virtude de seu caráter preponderante, deverá compensar a reincidência.

Nessa quadra, resta inalterada a pena base.

A seu turno, na terceira e última fase do sistema trifásico, deixo de considerar a incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, tendo-se em linha de conta o fato de a ré se tratar de reincidente específica.

Nessa quadra, a pena definitiva resta fixada no patamar de em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

O regime de cumprimento de pena deve ser estabelecido em conformidade com o quantum de pena fixado, considerando-se, outrossim, as circunstâncias judiciais e a reincidência.

Nessa arquitetura, fixo a título de cumprimento inicial de pena o regime fechado, notadamente ao ser considerada a reincidência específica.

A reincidência específica alija a perspectiva de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No mesmo toar, no caso em tablado, não se cogita da suspensão condicional da execução da pena.

Sem embargo do respeito tributado aos argumentos alteados pela Ilustre Defensora, no caso vertente, conforme salientado, o pedido de prisão domiciliar não deve ser albergado.

A rigor, a ré não demonstrou o seu enquadramento no esquadro normativo.

De ver-se que, no caso em tela, apesar da juntada de certidões de nascimento dos filhos da ré (fls.65/66), o Conselho Tutelar não logrou êxito na localização das crianças (fls.201/203), não havendo por parte da ré a produção de qualquer halo de prova a demonstrar que era a responsável pessoal, direta e exclusiva dos menores, não havendo outros parentes responsáveis por sua guarda.

Como apanágio, com fincas nos fundamentos expendidos, indefiro o requerimento formulado, sem prejuízo de melhor análise pelo juízo da execução penal, diante de novos elementos de convicção.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de CONDENAR a ré CLEUDIANE BATISTA, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A multa terá correção monetária desde a data do crime.

Diante do regime de pena imposto (fechado), mantenho a custódia cautelar da ré, notadamente diante de permanecerem inalterados o cenário e fundamentos que ensejaram a sua prisão.

De toda sorte, em casos tais, no comenos oportuno, deverá ser expedida guia de execução provisória ao juízo da execução penal competente, observando-se, por necessário, o regime prisional estabelecido na sentença.

Observe-se, por seu turno, a Resolução nº113/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 9º A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º.

Neste eito, diante da interposição de recurso, expeça-se guia de execução provisória, nos termos do artigo nono da referenciada Resolução, cabendo salientar que a interposição de recurso pelo Ministério Público objetivando o aumento da pena

não interdita a expedição da guia de execução provisória, porquanto na contingência de ocorrer o aumento da pena, proceder-se-á a novo cálculo, de molde a permitir a inferência se, diante da nova pena, a sentenciada teria o lapso para progressão, podendo, outrossim, haver a readequação do regime imposto.

De outra banda, em caso de eventual progressão, diante do redimensionamento da pena, com a sua exasperação, caso não ostente mais lapso suficiente, sendo necessário poderá ser expedido novo mandado de prisão, caso, por evidente, tenha progredido para regime mais benéfico.

Recomende-se a ré na prisão onde se encontrar.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do corré, com suas devidas identificações, acompanhadas de cópia deste pronunciamento judicial, c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) adotem-se as cautelas legais, arquivando-se com baixa, após a certificação, se o caso, da ausência de pendências.

Com o trânsito em julgado, caso ainda não tenha sido providenciado, determino a destruição da droga apreendida, oficiando-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72 da Lei de Drogas.

A seu turno, no concernente aos demais bens apreendidos, notadamente uma mochila; um cartão bancário; dez unidades de vestuário; um bicho de pelúcia; um adorno do tipo corrente de metal, de cor prateada; um telefone celular Samsung, modelo Galaxy J2 Prime, cor preta, não havendo prova de sua vinculação com o tráfico, o que não pode ser presumido, devem ser restituídos ao seu titular, a partir do trânsito em julgado, mediante prova da propriedade.

Caso certificado pela serventia no que concerne ao aparelho de telefonia móvel que não há laudo denotativo de sua instrumentalização para o tráfico deverá ser restituído ao seu proprietário.

P.I.C.

Jales, 22 de agosto de 2022.

Fábio Antonio Camargo Dantas

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA